

刑法
No98

共通問題 R7-2

(配点: 2)

月 日

月 日

学生A及びBは、【事例】について、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑪までの()内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑪までの()内には、それぞれ異なるものが入る。

【事例】

甲は、乙所有の飼い犬(以下「乙犬」という。)が甲所有の飼い犬(以下「甲犬」という。)に突然襲い掛かったため、甲犬を守る目的で、持っていた甲所有の傘で乙犬を殴り、乙犬に怪我を負わせた。

【会話】

学生A. 乙犬が甲犬に襲い掛かったことについて、乙に故意・過失が(①)場合、甲が乙犬に怪我を負わせた行為に(②)の成立を認めるかが問題になりますね。

学生B. 私は、「(③)」は人間の行為に(④)と考えるので、(②)の成立を(⑤)。そのため、(⑥)の成否が問題になります。

学生A. (⑦)と(⑧)を必要とする(⑥)の限度でしか対抗できないというのでは、(⑨)の保護が不十分ではないですか。

学生B. 乙に故意・過失が(⑩)場合、(②)が成立し得るので、不都合はありません。

学生A. (⑥)の法的性格について、どう考えますか。

学生B. (⑥)は、(⑦)を要件としているので、違法性阻却事由であると考えます。

学生A. そうすると、(⑥)に当たる行為に対して(②)は(⑪)ことになりますね。

【語句群】

- a. ある b. ない c. 正当防衛 d. 緊急避難
e. 不正の侵害 f. 現在の危難 g. 限られる h. 限られない
i. 認めます j. 認めません k. 補充性 l. 法益均衡
m. 甲 n. 乙 o. 成立し得る p. 成立し得ない

1. ①a ③f ⑤i ⑨n ⑩b
2. ①b ④g ⑦k ⑧l ⑩a
3. ②c ⑤j ⑦l ⑨m ⑪o
4. ②d ④h ⑥c ⑩b ⑪o
5. ③e ⑥d ⑧k ⑩a ⑪p

No98

正当防衛と緊急避難

正答率

共通R 7-2

正解

5

56%

()には順に、「①= b、②= c、③= e、④= g、⑤= j、⑥= d、⑦= l、⑧= k、⑨= m、⑩= a、⑪= p」と入り、したがって、正解は肢5となる。

①、②について

①、②については、学生Aの第一発言のみでは決められないが、選択肢を見ると、①には「a. ある」又は「b. ない」が、②には「c. 正当防衛」又は「d. 緊急避難」が入りそうであることがわかる。そして、学生Aの第二発言を見ると、「(⑦)と(⑧)を必要とする(⑥)の限度でしか対抗できないというのでは、(⑨)の保護が不十分ではないですか。」としており、⑦、⑧が補充性、法益均衡の要件について発言しているといえ、⑥は緊急避難であることがわかる。よって、②には「c. 正当防衛」が入る。そして、設問の事例の乙に故意・過失がある場合は「不正対正」の関係から正当防衛が成立し得るので、正当防衛の成立が問題となるのは乙に故意・過失がない場合である。よって、①には「b. ない」が入る。

③、④、⑤、⑥について

⑥に「d. 緊急避難」が入るとすると、学生Bの第一発言では、緊急避難の成否が問題になるとしていることから、正当防衛の成立を否定していると考えられる。このことから、学生Bは、正当防衛における不正の侵害という要件は、人間の行為に限られると考え、設問の事例の甲には正当防衛が成立しないと主張しているといえる。よって、③には「e. 不正の侵害」が入り、④には「g. 限られる」が入り、⑤には「j. 認めません」が入る。

⑦、⑧、⑨について

⑦、⑧については、「k. 補充性」、「l. 法益均衡」が入ると考えられる。どちらがどちらに入るかについては、学生Bの第三発言が手掛かりになる。ここでは、「(⑥= d. 緊急避難)は(⑦)を要件としているので、違法性阻却事由であると考えます。」としている。緊急避難の法的性質を違法性阻却事由であるとする説は、法益均衡を緊急避難の成立要件としていることを根拠の一つとしている。よって、⑦には「l. 法益均衡」が入り、⑧には「k. 補充性」が入る。そして、上記解説のとおり、⑥には「d. 緊急避難」が入るところ、正当防衛ではなく、補充性と法益均衡という要件により、成立が厳格な緊急避難の限度でしか対抗できなくなることで、甲に犯罪が成立してしまう可能性が高くなる結果、同人の保護が不十分となる。よって、⑨には、「m. 甲」が入る。

⑩について

正当防衛の本質は「不正対正」であることから、設問の事例の乙に故意・過失があれば、正当防衛が成立し得る。よって、⑩には「a. ある」が入る。

⑪について

学生Aの第四発言を見ると、「そうすると、(⑥= d. 緊急避難)に当たる行為に対して(②= c. 正当防衛)は(⑪)ことになりますね。」としており、これは、直前の学生Bの第三発言における、緊急避難は違法性阻却事由であるとする主張に対する意見である。緊急避難を違法性阻却事由とすると、その緊急避難が成立すれば違法性が阻却されるので、緊急避難行為に対する行為は「不正対正」の関係にはならず、正当防衛は成立し得ないことになる。よって、⑪には「p. 成立し得ない」が入る。